

1527265-34.2019.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Daniela Pazzeto Meneghine Conceição

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 11ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FABIO FISCHER e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Daniela Pazzeto Meneghine Conceição.

Vistos,

EDUARDO FUSCO FILHO e FABIO FISCHER foram denunciados como incurso no artigo 33, "caput" da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 13/11/2019, por volta das 08:20 horas, na rua ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

11ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, 1º andar, sala 189 - Barra Funda

CEP: 01133-020 - São Paulo - SP

Telefone: (011) 2127-9021 - E-mail: sp11cr@tjsp.jus.br

1527265-34.2019.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1527265-34.2019.8.26.0228 - 2019/002345

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FABIO FISCHER e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Daniela Pazzeto Meneghine Conceição.

Vistos,

EDUARDO FUSCO FILHO e FABIO FISCHER foram denunciados como incurso no artigo 33, "caput" da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 13/11/2019, por volta das 08:20 horas,

na rua Carlos Sodero, altura do nº 15, bairro Tucuruvi, nesta cidade e comarca de São Paulo, transportavam substância entorpecente ou que determina dependência física ou psíquica, mais precisamente 190,7 gramas (total) da substância conhecida como "haxixe", acondicionada parte em porções individuais e parte em cigarros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida em 01 de dezembro de 2019 (fls. 164/166).

Os réus constituíram advogado e apresentaram defesas prévias (fls. 182/196 e 233/247).

Mantido o recebimento da denúncia (fls. 261), foi designada audiência de instrução e julgamento (fls. 266/268).

Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas de acusação e de defesa e, ao final, os réus foram interrogados.

À seguir, o Ministério Público procedeu ao aditamento da denúncia para a inclusão da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06. Após manifestação da defesa, o aditamento foi recebido e, diante do desinteresse das partes na produção de outras provas, foi encerrada a instrução processual (fls. 339 e 349).

Em debates, o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia e aditamento.

A defesa, por sua vez, requereu a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação para uso de entorpecentes, o reconhecimento do tráfico-privilegiado, a fixação da pena no mínimo legal, a imposição de regime aberto, com substituição por penas alternativas, e o direito de apelar em liberdade.

É O RELATÓRIO DECIDO

A pretensão acusatória merece acolhida, porém não nos exatos termos da denúncia.

A prova da materialidade delitiva está consubstanciada no auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência nº 3957/2019 (fls. 03/07), auto de exibição e apreensão (fls. 08/10), laudo de constatação preliminar (fls. 115/124), laudo pericial (fls. 223/225), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 286/288), e pela prova coligida aos autos.

Segundo consta na denúncia, policiais militares estavam em patrulhamento de rotina, quando avistaram o veículo de placa QX838 parado e, dentro dele, em atitude suspeita, estavam os réus, EDUARDO FUSCO FILHO e FABIO FISCHER.

Abordados e revistados, nada de ilícito foi localizado com os agentes, sendo que na carteira de FÁBIO localizaram R\$ 457,00. Em busca no veículo, os policiais localizaram uma bolsa contendo o valor de R\$ 1.076,00, uma balança de precisão, 18 invólucros de substância entorpecente (haxixe), um cigarro parcialmente consumido de maconha e a carteira de trabalho de EDUARDO, sendo a bolsa de sua propriedade.

Ainda, dentro do veículo, os policiais localizaram um estojo, no qual havia dois invólucros de maconha, uma tesoura e dois debulhadores. Por fim, no cinzeiro do veículo e no porta-moedas localizaram, ao todo, mais dois cigarros parcialmente consumidos de maconha.

Em solo policial, os réus Eduardo Fusco Filho e Fábio Fischer assumiram a

propriedade da droga, mas negaram a traficância (fls. 22 e 23).

Eduardo afirmou ser pessoa idônea, de família, sustentado seu filho. À época dos fatos, trabalhava com venda de modelador no mercado livre há um ano e trabalhou em outros locais. Iniciou duas faculdades. Arrepende-se de estar aqui. Usa droga (maconha e derivados, como por exemplo haxixe) desde os 15 anos, considerando-se usuário. Pagou pela droga R\$ 350,00 e Fabio pagou a outra metade. Naquele final de semana, iria a casa de um amigo em Bananal, em um sítio, onde provavelmente passariam o final de semana. Iriam oito pessoas ao sítio, sendo que sabe que seis pessoas usam droga, porém, esta droga era de uso exclusivo do interrogado e de Fabio. Uma parte da droga ficaria com o interrogado em casa e outra parte iria levar no sítio. A quantidade era grande por conta de sua segurança nos locais de compra. Sua intenção não era desonrar os policiais, que foi no calor do momento da situação. Não estava traficando o entorpecente. Conhece Fabio da faculdade fazia três ou quatro anos. Nunca comprou droga em conjunto com Fabio. Cada embalagem tem 10g de haxixe e custa em torno de R\$ 80,00 cada invólucro, dependendo da qualidade, e que pagou bem mais barato devido a quantidade comprada. O dinheiro apreendido em seu poder, R\$ 312,00, era para a compra de ingressos de show e R\$700,00 de sua propriedade. Iria no sítio de um colega da faculdade. Quando os policiais chegaram para lhe abordar, o interrogado estava colocando no carro o cooler que iria levar na viagem. Quando foi surpreendido pelos policiais teve uma péssima reação, com medo. Sua intenção não foi reagir, mas reflexo do susto que passou. A respeito da balança de precisão, não sabia de sua existência. (fls. 23).

Fabio declarou que locou o veículo para trabalhar como Uber, pagando semanalmente o valor de R\$ 392,00, sendo o veículo alugado da empresa Localiza. Tinha se programado para viajar naquele final de semana, e iria ficar hospedado na casa de um amigo da faculdade, na cidade de Bananal, onde iria conhecer o sítio que provavelmente passariam o final do ano. Resolveu comprar uma quantidade de haxixe pelo valor de R\$ 700,00, tendo sido rateado entre o interrogado e Eduardo e a substância seria para uso próprio do interrogado e de Eduardo. Ficariam no sítio uns 10 dias. O haxixe foi adquirido na favela do Heliópolis, mas não sabe o nome e nem demais dados da pessoa que lhe vendeu a substância. A balança era para conferir o peso do que estava pagando. Conhece Eduardo da faculdade. O interrogado fazia turismo e Eduardo fazia outra matéria. O conhecia há seis meses. Usa droga desde os 16 anos de idade e é dependente de maconha e haxixe. O dinheiro que estava em seu poder, R\$ 457,00 é proveniente do UBER. Trabalhava no Uber fazia três meses, mas trabalhou com corretagem de imóveis há dez anos e já teve outros trabalhos com carteira assinada. (fls. 22).

Em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, os réus negaram a prática delitiva.

O réu Eduardo Fusco Filho afirmou que no dia dos fatos, estava na companhia do corréu Fábio, se preparando para viajarem para o sítio de seu amigo Rodrigo, localizado na cidade de Bananal, quando foram abordados pelos policiais. Admitiu ser usuário de maconha e haxixe desde seus 16 anos, já tendo, inclusive, após os fatos, se submetido a tratamento, porém não conseguiu se livrar do vício. Disse que as drogas encontradas eram para consumo próprio e as havia adquirido na comunidade de Heliópolis, local que costumeiramente comprava os entorpecentes, tendo pago o valor de R\$ 700,00, quantia esta dividida entre os dois. Declarou que a droga havia sido comprada no período da manhã, antes da viagem, vindo em seguida passar em sua residência para prepararem as malas. Também foram apreendidos dois cigarros de maconha no interior do veículo, os quais estavam parcialmente consumidos, pois haviam acabado de fumar. Aliás, afirmou que por ocasião da abordagem estavam fumando maconha. Declarou que o veículo em que estavam havia sido alugado pelo corréu Fabio, pois na época ele trabalhava com "Uber". Além das drogas, também foi apreendida uma balança de precisão que pertencia ao corréu Fabio, pois ele pretendia conferir a pesagem da droga adquirida a fim de não ser ludibriado pelos

traficantes e, caso não correspondesse à quantia, certamente mudaria de fornecedor. Não tinha ciência da existência desta balança no veículo alugado pelo corréu Fabio. Disse que as drogas foram vendidas em porções individuais, pronto para consumo. Declarou que pretendia pesar a droga no interior da sua residência, porém acabaram sendo abordado pelos policiais. Foi abordado em frente a sua casa, local este que fica nas proximidades de duas escolas. Primeiro vieram quatro policiais e depois mais dez policiais e, após revistarem sua residência, com a autorização de seu pai, nada de ilícito foi encontrado. Quanto à tesoura e dichavador apreendidos, utilizavam para destrinchar a maconha e confeccionar o cigarro para consumo pessoal. Relatou que trabalha com instalação de portões e câmeras de segurança, tem filho e que mora com seu pai.

Já o réu Fábio Fischer disse que havia adquirido a droga na madrugada, na favela de Heliópolis, ocasião em que adquiriram 18 porções de haxixe, tendo pago a quantia de R\$ 700,00, a qual seria dividida com o corréu Eduardo. Afirmou ser apenas usuário de droga e jamais pretendia vendê-las. Pretendiam consumir a droga no sítio que pretendiam passar o feriado. Estavam na porta da residência do corréu Eduardo quando da abordagem pelos policiais, sendo que estavam fumando maconha quando da chegada dos militares. Disse ter adquirido a balança naquele dia com a intenção de conferir a quantidade adquirida. Declarou que o carro era alugado e que o utilizava para trabalhar como "Uber". Neste dia ia fazer a pesagem no carro e depois fazer a divisão da droga com o corréu Eduardo. Declara ser usuário de maconha e haxixe desde seus 16 anos, sendo que depois do ocorrido iniciou um tratamento, mas acabou tendo uma recaída. Não chegou a cogitar de fazer a pesagem da droga na casa do Eduardo e que referido réu não sabia da existência da balança, obtendo ciência do objeto somente no momento da abordagem. Disse que estavam levando cigarros de maconha, os quais estavam parcialmente consumidos. Afirmou que os policiais revistaram a casa do corréu Eduardo, mas nada de ilícito foi encontrado.

E neste sentido, tem-se que a fala dos réus, não se encontram isoladas com o restante do conjunto probatório.

Vejamos a prova do contraditório:

A testemunha Vitor Vieira de Andrade de Jesus, policial militar e presente na diligência declarou que estava em patrulhamento quando uma Senhora informou à equipe que sua filha tinha sido vítima de roubo. Após patrulhamento, disse que ouviu um barulho vindo de um veículo que estava parado assim como um forte cheiro de maconha não tendo visto, porém, os réus fumando. Feita a abordagem, localizaram os dois réus e com eles nada de ilícito foi encontrado. Em revista veicular foram encontradas uma porção de haxixe, dinheiro, um cigarro de maconha, uma tesoura e uma balança de precisão. Não se recorda o que os réus alegaram em razão da abordagem nem a quantia de dinheiro encontrada. Disse que as porções de haxixe estavam embaladas em forma de cubículos quadriculados, somando aproximadamente 18 porções. Não havia outras pessoas próximas ao local dos fatos e que afirmou que o depoimento de fls. 20 é o seu dado em solo policial, lembrando que por ocasião da abordagem os réus afirmaram que as drogas eram para consumo próprio. Disse ainda que havia cigarros de maconha parcialmente consumidos não se recordando a quantidade exata. Uma dos réus morava próximo ao local da abordagem e que não se recorda se foram feitas buscas na residência.

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha Marianna Nanni Batalha, também policial militar e presente na diligência. Afirmou que se encontrava em patrulhamento de rotina, à pé, quando avistaram no local dos fatos os réus. Após revista veicular encontraram o haxixe. O local fica próximo a duas escolas, não se recorda o nome, mas fica bem próximo ao local de abordagem. A casa do Eduardo fica próximo ao local da abordagem. Também foram encontrados, tesoura e plásticos. Quanto à balança de precisão, não se recorda ao certo. Declarou que no momento da

abordagem havia um grande odor de maconha, o que levou a abordagem. Mas não presenciou eles fumando a droga. Também foi encontrado um cigarro de maconha dentro do veículo e dois parcialmente consumidos. Na ocasião os réus falaram que a droga era para uso próprio e pelo que se recorda não foi realizada revista na casa dos réus. Sabe apenas que conversaram com familiares do Eduardo.

Com efeito, conforme constam de seus depoimentos, não há nenhuma circunstância que indique a realização do comércio ilícito por parte dos réus, eis que a abordagem apenas se deu por conta do forte odor de maconha que vinha do veículo em que os acusados estavam, tendo os policiais afirmado ainda, que não havia outras pessoas próximo ao local dos fatos.

Ademais, após revista veicular, os policiais encontraram cigarros de maconha parcialmente consumidos e 18 porções de haxixe que, segundo os réus, seriam destinados ao consumo próprio, já que estavam se dirigindo a um sítio de um amigo, local em que a droga seria consumida.

E, neste sentido, a testemunha de defesa Rodrigo Kukrecht Fonseca, confirmou tal versão. Disse que conhece Eduardo há vários anos e que ele não foi ao seu sítio porque havia sido preso, não sabendo até então o motivo. Declarou que o sítio é de seu pai e que sabe que o réu Eduardo usa drogas, como haxixe e maconha, e que já chegaram a utilizar juntos. Afirmou que o referido réu trabalha com instalação e manutenção de câmeras de segurança e que na viagem mencionada ele iria levar o corréu Fabio. Desconhece qualquer envolvimento do réu Eduardo com o tráfico de drogas. Afirmou que estava com seu pai no sítio, não se recordando se sua namorada lá já estava. Disse que provavelmente sua namorada também havia chamado a namorada de Eduardo para também ir ao sítio. O réu Eduardo tinha costume fumar haxixe, não sabendo se Fabio também fumava. Conhecia Fábio, mas não tem muito contato quanto com Eduardo. Afirmou que chamou os acusados para irem ao seu sítio, nada sabendo sobre eventual aluguel de chácaras pelos réus.

Assim, a versão apresentada pelos acusados de que a droga teria sido adquirida em conjunto para consumo posterior, não deve ser desconsiderada, eis que de acordo com o conjunto probatório.

Nem a quantidade de droga encontrada em poder dos réus indica o contrário, já que apreendida pequena quantia (18 porções de haxixe) que, se dividida por dois, daria nove porções para cada, a ser consumida por vários dias.

Quanto à natureza dos apetrechos apreendidos (tesoura, dichavador e balança), por si só, não são elementos indicativos de que as drogas eram destinadas à consumo de terceiro, até porque, tais objetos são comumente utilizados por usuários.

Assim, a desclassificação para o delito de uso de entorpecente é medida que se impõe.

Destarte, assentes estão a materialidade e autoria delitiva, e a conduta dos réus se subsume-se ao crime tipificado no art. 28, caput, da Lei nº 11.343/06.

Passo a dosar a pena do réu.

A nova Lei de Drogas – Lei nº. 11.343, de 2 de agosto de 2006, trouxe novas determinações quanto ao delito imputado ao réu.

Essa nova lei, além de trazer várias novidades, revogou expressamente a antiga lei de entorpecentes, conforme dispõe seu artigo 75.

O fato que recai sobre os acusados e que era tipificado no artigo 16 da lei antiga, passou a ter previsão no artigo 28, trazendo como maior inovação a

despenalização do uso de entorpecentes.

O revogado artigo 16 previa pena de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos de detenção, além do pagamento de até 50 (cinquenta) dias multa, sendo que o novo delito de uso de drogas traz como sanções a (I) advertência sobre os efeitos das drogas, (II) a prestação de serviços à comunidade e a (III) medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo.

Como se vê, não há mais pena de prisão.

Assim, levando-se em consideração a ínfima quantidade apreendida, ou sua imprecisão, entendo coerente sancionar os acusados com a pena de advertência sobre os efeitos das drogas.

Posto isto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão acusatória para condenar EDUARDO FUSCO FILHO, RG: 49.229.443, CPF: 366.008.538-32, nascido em 13/02/1991, natural de São Paulo - SP, filho de Eduardo Fusco e Eleonice Fusco e FABIO FISCHER, RG: 32.317.287, CPF: 328.786.608-70, nascido em 06/04/1984, natural de São Paulo - SP, filho de Edson Borba Fischer e Rosely Foresti Fischer, a serem advertidos sob os efeitos das drogas, por violação ao art. 28, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Fica autorizada a incineração das drogas apreendidas se acaso tal providência ainda não tiver sido realizada, nos termos do art. 32 e parágrafos da Lei 11.343/06.

Nos termos do artigo 63, caput e §1º, da Lei 11.343/2.006, determino o perdimento do valor apreendido em favor da União.

Declaro a perda dos demais objetos apreendidos com os réus (balança de precisão, estojo, bolsa, dichavadores e tesoura - fls. 08/10), porquanto relacionados à traficância. Autorizo a destruição.

Quanto ao veículo apreendido, que está em nome de terceiro, pois se trata de veículo locado pelo réu Fábio (fls. 09), autorizo a restituição mediante comprovação de propriedade.

Condeno os réus ao pagamento das custas equivalentes a 100 UFESP's, nos termos do art. 4º, § 9º, alínea "a" da Lei nº 11.608/03.

Após o trânsito em julgado, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo GumbletonDaunt - IIRGD; oficie-se ao e. TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da CF; expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-a ao Juízo competente.

P.R.I.

São Paulo 25 de agosto de 2022

Daniela Pazzeto Meneghine Conceição

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA